



**משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים**

בפני כב' המפקח ש. הייזלר

תיק מס': 60/11

התובעים:

1. ערן אליצור

2. אורן שמני

ע"י ב"כ עו"ד אורן שמני

- נ ג ד -

הנתבעת:

ענת אלפי

ע"י ב"כ ארז גמליאל

פ ס ק - ד י נ

עניינה של התביעה - דרישת התובעים להורות לנתבעת לסלק ידה מחלל המצוי בבית המשותף בגוש 30010 חלקה 49 (להלן: "הבית המשותף"), ולהשיב את מצב החלל לקדמותו, ובכלל זה להרוס קונסטרוקציה וקירות ממ"ד שנבנו על ידה בחלל.

א. רקע עובדתי:

1. המדובר בבית המשותף ברחוב הצפירה 14 בירושלים, הבנוי במקרקעין הידועים כגוש 30010 חלקה 49.
2. בבית המשותף 6 דירות. התובעים הינם הבעלים של דירות מס' 5-6, והנתבעת הינה בעלת דירה מס' 1. דירה מס' 6, אשר בבעלות התובעים, מוחכרת לתקופה של 999 שנה לה"ה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- סמט יקותיאל ונורה (להלן: "סמט"). דירה מס' 2 הינה בבעלות ה"עובדיה יעקב ורינה (להלן: "עובדיה"), ודירה מס' 3 הינה בבעלות הגב' צור פנינה (להלן: "צור").
3. דירה מס' 4 הינה בבעלות הגב' גרוסמן מרים, ולא היתה מחלוקת כי היא לא נתנה הסכמה לבנייה המבוקשת על ידי הנתבעת.
4. ביום 10.1.11 קבלה הנתבעת היתר בניה מס' 102403 לתוספת בניה של ממ"ד ומחסן בשטח כולל של 17.37 מ"ר [נספח ה' לתצהיר התובעים]. על פי היתר הבניה, תוספת הבניה אמורה להיבנות בחלל המצוי תחת חלק מדירת הנתבעת (דירה מס' 1), תוך הגבהת מפלס הקרקע של דירה מס' 1 באזור שמעל תוספת הבניה.
5. ביום 15.3.11 הגישו התובעים תביעה כנגד הנתבעת, במסגרתה טענו כי הנתבעת פולשת לרכוש המשותף, שלא כדין.
6. בכתב ההגנה שהגישה הנתבעת ביום 17.4.11, טענה הנתבעת כי היא קבלה את ההסכמות הדרושות לצורך הבניה, ופעלה על פי הנדרש ממנה.
7. ביום 23.10.11 התקיים דיון הוכחות, ולאחריו הגישו הצדדים סיכומיהם בכתב.

ב. טענות התובעים:

8. לטענת התובעים, הנתבעת מבצעת בניה שלא כדין ברכוש המשותף, זאת מאחר שאין ספק כי מסד הבית המשו תף מהווה רכוש משותף, ונוכח העובדה כי הנתבעת לא הציגה את הרוב הדרוש בחוק המקרקעין התשכ"ט-1969 [להלן: "החוק"], על מנת שיותר לה לבנות בשטח זה.
9. בהקשר זה טוענים התובעים, כי אין תוקף משפטי כלשהו לחתימותיהם של צור, עובדיה וסמט, וזאת ממספר נימוקים.
01. בראש ובראשונה, משום שחתימותיהם ניתנו לצורך ההליך התכנוני ואינן מהוות הסכמה המעידה על ויתור על חלק מרכוש המשותף. בנוסף, כך לטענת התובעים, אין ליתן משקל לחתימות הללו, לאור העובדה שצור, עובדיה וסמט, לא העידו על חתימתם, והנתבעת אף לא טרחה לזמנם לעדות. התובעים טוענים עוד, כי הוכח ש הנתבעת לא המציאה להם את התכניות כלל, וכן הוכח שהנתבעת לא הציגה לצור, עובדיה וסמט, את תכניות הבניה לפני שבקשה מהם לחתום על הסכמתם למתן ההיתר. בעניין זה מפנים התובעים לעדות הנתבעת בעמוד 8 שורה 26 לפרוטוקול, ולעמוד 9 שורה 17 לפרוטוקול שם העידה הנתבעת כי התכנית שנתנה למתן ההיתר. התובעים אף צירפו



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- לסיכומיהם מסמך נוסף המעיד, לטענתם, כי התכנית לא הוצגה לצור עובדיה וסמט בטרם חתימתם.
11. בכל הנוגע לחתימתה של צור, נטען על ידי התובעים כי היא נעדרת תוקף, בהיותה סותרת את ההסכם שנחתם בינה לבין התובעים, אשר קבע "שלא תהיה חריגה מקונטרס הבניין כפי שהוא קיים היום בפועל", ואת יפוי הכח הבלתי חוזר שנתנה צור לתובעים, במסגרתו העבירה לתובעים את הזכות לחתום ולהסכים לכל היתר בניה. התובעים אף מדגישים כי הגב' צור קבלה תמורה על כך, ובכך ויתרה על זכויותיה כאמור.
21. אשר לחתימת עובדיה נטען על ידי התובעים, כי הם סבורים שאין ליתן לה משקל כלשהו הן משום שלא חתמו על הסכם כולל, הן משום שלא הגיעו להעיד בהל"ך, והן משום שחתימה על טופס הסכמה לעירייה, אינה מהווה הסכמה להוצאת חלקים מהרכוש המשותף.
31. התובעים מוסיפים, כי הנתבעת אף העלימה מעובדיה וצור את העובדה כי ניתן לעשות שימושים משותפים נוספים בקומת הקרקע, ולו היו יודעים זאת לא היו חותמים כלל וכלל.
41. לטענת התובעים, הנתבעת היתה מודעת לכל המתרחש בבית המשותף, ובכלל זה, להסכמים השונים שנכרתו עם עובדיה וצור, הן משום שהתגוררה בסמוך, והן לאור העובדה שלאורך כל הדרך לוותה על ידי אחיה ואביה, שהינם, לטענת התובעים, יזמי נדל"ן. התובעים מפנים גם לעדות הנתבעת, ממנה עולה, לטענתם, כי הנתבעת ידעה על אותם הסכמים עם עובדיה וצור, עוד בטרם רכשה את דירתה.
51. אשר לדירה מס' 6, טוענים התובעים כי ה"ה סמט הינם חוכרים של הדירה, ועל פי הדין הכללי כמו גם על פי הסכם החכירה, אין הם רשאים לחתום על הסכמתם להרחבה. לטענת התובעים, רק הם אלו שרשאים ליתן ההסכמה להרחבה מטעם דירה מס' 6, בהיותם בעלי הדירה. התובעים אף מדגישים, כי העובדה כי סמט הינם חוכרים ולא הבעלים של דירה מס' 6, היתה בידיעת הנתבעת, ומוסיפים כי הוכח שהנתבעת ידעה לאורך כל הדרך על התנגדותם לבנייה.
61. לטענת התובעים, בכל מקרה, אין תוקף להסכמות שניתנו, שכן החלטה על ויתור על זכות ועל מתן הסכמה להרחבה, אמורה להתקבל במסגרת אסיפה כללית, ובהיעדרה, אין כל משקל להסכמה.
71. לטענת התובעים, גם אם תיטען כי בוצעה הרחבה באחת מהדירות בבית המשותף, הרי שהמחסן המצוי בחצר הבית המשותף בו משתמשת הנתבעת, בגודל של כארבעה מ"ר,



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- מהווה כבר הרחבה דומה לכל הרחבה אחרת, ולפיכך אין ליתן לנתבעת ליהנות מהרחבה נוספת. בהקשר לכך מוסיפים התובעים, כי לאור מהות השימושים המבוצעים במחסן זה, ההסכמות שניתנו ומידת הפגיעה, יש לראות במחסן כהרחבה דומה להרחבה שבוצעה בדירה מס' 6, אף שאין מדובר בהיקף זהה.
81. כך או כך, לטענת התובעים, אין לראות בהרחבה שמבקשת הנתבעת לבצע בדירתה, הרחבה דומה להרחבה שבוצעה בדירה מס' 6, הן לאור גודלה של ההרחבה, והן לאור מהותה, טיבה, ומידת הפגיעה ביתר בעלי הדירות העלולה להיגרם כתוצאה מההרחבה.
91. התובעים מוסיפים, כי הנתבעת יכולה להקים את הממ"ד בשטח העמודה המוצעת על ידם, וכך להותיר את הקרקע שתחת הבית המשותף לשימוש הכללי. על כן, כך לטענת התובעים, אין ליתן לנתבעת לבצע את ההרחבה שעלולה לקפח את זכויותיהם של בעלי הדירות הנוספים. התובעים טוענים עוד כי בניית הממ"ד בעמודה אחת נדרשת לאור סעיף 197(א)(3) לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), תש"ן-1990.
02. לטענת התובעים, בניית מחסן וק ונסטרוקציה בקומת המרתף, אינה בגדר הרחבת דירה ולפיכך נדרשת הסכמה של 100% מבעלי הדירות.
12. כן טוענים התובעים כי בפועל, הנתבעת אף מבצעת בניה הגדולה בהיקפה מ המותר בהיתר הבניה.
22. לטענת התובעים, יש להורות על השבת המצב לקדמותו ולא להסתפק במתן צו המורה לנתבעת לאטום את החפירה. לטענתם, התנהלות הנתבעת וחוסר תום ליבה, מחייבים מתן צו שכזה, שאם לא כן, יצא חוטא נשכר.
32. לאור כל האמור, דורשים התובעים לקבל את התביעה על כל רבדיה, ולהורות לנתבעת להשיב את המצב לקדמותו.

ג. טענות הנתבעת:

42. מן העבר השני טוענת הנתבעת, כי באמתחתה הרוב הדרוש לביצוע ההרחבה בהתאם לסעיף 71ב לחוק, וודאי לצורך בניית הממ"ד. בתוך כך, טוענת הנתבעת כי על בקשתה להיתר חתמו בעליהן של 4 מתוך 6 מהדירות, ודי בכך כדי לאפשר לה בניית ממ"ד, הדורשת הסכמה של 60% מבעלי הדירות.
52. לטענתה, לצורך קבלת היתר הבניה, היא קבלה את הסכמתם של בעלי דירה 2 [עובדיה], דירה 3 [צור], ואף את הסכמתם של בעלי זכות החכירה ל- 999 שנה בדירה 6 [סמט].



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- הסכמה זו, כך לשיטתה של הנתבעת מהווה הסכמה לכל דבר ועניין, לאור ההלכה הפסוקה, הקובעת, לטענתה, כי ההסכמה שהוענקה על ידי בעלי הדירות לצורך היתר הבניה, מהווה גם הסכמה לצורך הרחבה בהתאם לסעיף 71ב לחוק.
62. לטענת הנתבעת, אין צורך באסיפה כללית לשם מתן הסכמה להרחבת דירה, וניתן להסתפק גם בחתימה פרטנית של כל בעל דירה.
72. הנתבעת מוסיפה וטוענת, כי במקרה דנן אין ספק כי בעלי הדירות שהסכימו להרחבה ידעו על מהותה. הנתבעת מפנה, בין היתר, לנספח ב' לתצהירה [להלן: "**כתב ההסכמה**"], עליו נכתב כי החותמים מצהירים כי ראו את תכניות הבניה ואין להם התנגדות לכך.
82. הנתבעת טוענת, כי לא היה מקום להזמנת החתומים על כתב ההסכמה, קרי, עובדיה, צור, וסמט, לדיון, שכן הנטל להוכיח כי חתימות אלו אינן קבילות, מוטל על התובעים. יתר על כן, כך לשיטת הנתבעת, התובעים עצמם הודו כי חתימות אלו הינן חתימות בעלי הדירות הרלוונטיות, אך טענו כי הן בעלות משקל רק בהליך התכנוני [בהקשר לכך מפנה הנתבעת לעמוד 4 לפרוטוקול]. מוסיפה הנתבעת, כי אף העובדה שהוועדה המקומית לתו"ב העניקה היתר בעקבות חתימות אלו, מלמדת כי יש ליתן אמון בחתימות המוצגות.
92. אשר לטענת התובעים שלפיה היתה מנועה צור מ להסכים לבקשת הנתבעת, מכח הסכמים קודמים, טוענת הנתבעת כי אין כל הוראה בהסכם בין התובעים לצור הקובעת זאת, ואף התובעים עצמם הודו בכך [הנתבעת מפנה לעמוד 4 שורה 39 לפרוטוקול]. בהקשר לכך מוסיפה הנתבעת כי לאור העובדה שלא היה בהסכמים בין התובעים לבין עובדיה וצור הוראה המגבילה את זכותם של עובדיה וצור ליתן הסכמתם לבניה המתבקשת על ידי הנתבעת, אין גם בייפוי הכח הבלתי חוזר שניתן על ידי עובדיה וצור לתובעים, כדי להגביל את זכותם של עובדיה וצור ליתן הסכמתם למבוקש על ידי הנתבעת.
03. יתרה מכך, כך טוענת הנתבעת, בכל הנוגע לדירה מס' 2 [עובדיה], הרי שאין צורך של ממש בחתימת בעליה, שכן בדירה זו בוצעה הרחבה של 22 מ"ר [הנתבעת מפנה לנספחים ו- ח לתצהירי התובעים].
13. הנתבעת מוסיפה כי היא לא ידעה כלל על אותם הסכמים שבין עובדיה וצור לתובעים, וכי הסכמים אלו נחתמו מספר שנים לפני שרכשה הנתבעת דירתה.
23. אשר לדירה מס' 6 – לטענת הנתבעת, סמט, שהינם בעלי זכות החכירה ל- 999 שנה, רשאים ליתן ההסכמה לבניית הנתבעת, ואין צורך לדרוש את הסכמת הבעלים. בהקשר לכך מפנה הנתבעת לסעיף 52 לחוק, כמו גם להסכם החכירה בין סמט לבעלים שאינו קובע, כך לטענתה, כי סמט לא יחשבו כבעל דירה לעניין פרק ו' לחוק.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

33. יתר על כן, כך טוענת הנתבעת, דירה מס' 6 הורחבה בכ- 10 מ"ר בעבר על חשבון הרכוש המשותף, ובנוסף שונה ייעודו של שטח של כ- 5 מ"ר לשטח עיקרי. ממילא, כך לשיטת הנתבעת, יש לראות את בעלי דירה מס' 6 כמי שהסכימו לבניה דומה על ידי הנתבעת. בהקשר לכך טוענת הנתבעת כי למרות ששטח ההרחבה המבוקש על ידה גדול משטח ההרחבה של דירה מס' 6, הרי שיש לראות בכך הרחבה דומה, לאור טיבה ומהותה.
43. מוסיפה הנתבעת וטוענת, כי לאור העובדה שהתובעים הינם בעלי הזכויות בדירה מס' 6, ולאור העובדה שכאמור יש לראות אותם כמסכימים לדרישת הנתבעת עקב הרחבה דומה, ונוכח היותם בעלי הזכויות גם בדירה מס' 5, יש לראות בנתבעת כמי שקבלה גם את הסכמתה של דירה מס' 5. מכאן עולה, כך לטענת הנתבעת, שלנתבעת יש רוב של 3/4 מבעלי הדירות, ויש לאשר את כל המבוקש על ידה בהיתר הבניה, קרי, הממ"ד והמחסן.
53. מכל מקום מוסיפה הנתבעת, כי התובעים עצמם ידעו על הבקשה להיתר שהגישה, ולא הגישו התנגדות למוסד התכנון. לפיכך, כך לטענת הנתבעת, יש לראות אף בתובעים כמסכימים לבקשה לבניה. כן מוסיפה הנתבעת וטוענת, כי על פי עקרון תוסף וס הלב ודוקטרינת השימוש לרעה בזכות יש להגיע למסקנה כי התובעים מנועים מלהתנגד להרחבה המתבקשת על ידי הנתבעת.
63. לטענת הנתבעת, נכון להיום, נוצלו כל אחוזי הבניה במקרקעין, ובשל כך התקבל היתר לשטחי שירות בלבד, קרי, מחסן וממ"ד. בנסיבות אלו, כך טוענת הנתבעת, אין כל בסיס לטענות התובעים בדבר פגיעה בזכויות הבניה שלהם.
73. הנתבעת מתנגדת לקבלת נספח א' לסיכומי התובעים, בטענה כי מדובר בראיה ש"הוגנבה" שלא כדין לסיכומי התובעים, ולא ניתנה לנתבעת ההזדמנות לחקור לגביה. הנתבעת אף טוענת כי לא ניתן ללמוד ממסמך זה דבר, שכן החותמת על גבי מסמך זה קטועה ולא ברור מה היא מציינת.
83. הנתבעת טוענת, כי כל טענות התובעים בסיכומיהם בנוגע למחסן בשטח של 4 מ"ר המצוי בחצר הינם בגדר שינוי והרחבת חזית ולפיכך יש לדחותן. לגופו של עניין, ובבחינת למעלה מהדרוש, טוענת הנתבעת כי מחסן זה אינו בשימוש ייחודי שלה, הוא לא נבנה על ידה, וכל בעלי הדירות רשאים לעשות בו שימוש. בתוך כך מפנה הנתבעת לעדותה בדיון שלפיה המחסן אינו שלה.
93. הנתבעת מתנגדת גם לטענות התובעים ביחס לשינוי מיקום הממ"ד, בהיותן בגדר שינוי והרחבת חזית. לגופו של עניין טוענת הנתבעת בהקשר זה כי הבניה המבוקשת על ידה לא תפריע למאן שהוא לבנות בחלקים נוספים של קומת המרתף שטחי שירות (בכפוף לקבלת



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

ההסכמות הנדרשות), שכן מדובר בשטח המשתרע על פני 147 מ"ר. כן נטען על ידי הנתבעת כי הסטת בניית הממ"ד למקום המוצע על ידי התובעים תב"א לפגיעה קשה בדירתה, שכן בניה במיקום זה תהפוך את חדר השינה לחדר פנימי ללא חלון. בנוסף, מפנה התובעת לכך שהשטח המצוי בעמודה המוצעת על ידי התובעים הינו פחות משמונה מ"ר, ואילו הממ"ד המבוקש על ידה הינו למעלה מ- 9 מ"ר, וזאת כמתחייב מסעיף 197א לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990.

04. הנתבעת מציינת גם, כי היא בחרה לבנות בחלל התת-קרקעי, למרות שבניה זו דורשת הגבהת מפלס דירתה, על מנת לא לפגוע בשכניה.
14. אשר לטענות התובעים, כי בניית מחסן וקונסטרוקציה אינה בגדר הרחבה, מפנה הנתבעת לסעיף 71ב לחוק, וכן לפסיקה הקובעת כי כל אימת שקיים חיבור פיסי בין החלקים הנדונים מדובר בהרחבה.
24. הנתבעת שבה ומדגישה, כי לא תחרוג מהיתר הבניה ולו בס"מ אחד, וממילא אין כל מקום לטעון כנגדה, כי הבניה המתבצעת על ידה גדולה בהיקפה על זו המותרת לה בהיתר הבניה.
34. הנתבעת טוענת, כי בכל מקרה אין מקום לחייבה להשיב המצב לקדמותו, וזאת ממספר סיבות: ראשית, מאחר שהיא פעלה בתום לב; שנית, לאור העובדה כי עד ליום 18.2.11 התובעים לא התנגדו לבניה; שלישית, מאחר שנכון להיום החלל אטום לחלוטין באמצעות יציקת בטון; רביעית, נוכח העובדה כי אין בחלל, ודאי בחלל האטום, כדי לפגוע בזכויות בניה קיימות במקרקעין, ולבסוף, משום שהתובעים עצמם אינם באים בניקיון כפיים שכן הם עצמם לא פעלו להריסת חלק דירתם [דירה 6] הבנוי על הרכוש המשותף שלא כדין.
44. הנתבעת מבקשת להדגיש, כי היא פעלה בתום לב, ובהתגלע המחלוקת אטמה את הגישה לחלל עד להכרעה בסוגיה. לאור כל האמור מבקשת הנתבעת לדחות את התביעה כנגדה.

ד. דיון והכרעה:

54. סעיף 71ב לחוק קובע כדלהלן:

"על אף הוראות סעיף 62(א) סיפה, או סעיף 12(ב) לתקנון המצוי שבתוספת, רשאים מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות ושני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, להחליט בדבר הוצאה של חלקים מסויימים מהרכוש המשותף והצמדתם לדירה פלונית, לשם בניה



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

שמטרתה הרחבת אותה דירה , וכן להחליט בדבר חלוקת זכ ויות הבניה הנדרשות לצורך זה , ואולם, היה נושא ההחלטה כאמור הרחב ת דירה פלונית אחת או יותר לשם בניית מרחב מוגן דירתי או מרחב מוגן קומתי, רשאים להחליט על כך מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות".

64. החוק מבחין בין הרחבה רגילה לבין הרחבה שמטרתה בניית ממ "ד. בעוד לצורך הרחבה רגילה דרושה הסכמת מי שבבעלותם שלושה רבעים מהדירות, אשר שני שלישים מהרכוש המשותף צמוד לדירותיהם, לצורך הרחבה שנועדה לבניית ממ"ד די בהסכמת רוב של מי שבבעלותם שישים אחוזים מהדירות.

74. הגדרת ה"הרחבה" הקבועה בסעיף 71 לחוק, הינה רחבה ביותר : "כל הגדלה המהווה המשך טבעי של הדירה ... יכולה הרחבה להיות אנכית , כגון, בניה על גג הבית , שהוא רכוש משותף וחיבור התוספת שנבנתה לדירה שמתחתיה . ההרחבה יכולה להיות גם אופקית, כגון בניית מרפסת או סגירתה , בניית פרגולה , בניה בחצר וחיבור התוספת שנבנתה לדירה קיימת בקומת הקרקע . התנאי להרחבה הוא כי ההרחבה תהא מתוך דירת המבקש " [ר' : א. אייזנשטיין, יסודות והלכות בד יני מקרקעין , חלק ג', 222, ההדגשה לא במקור ; ר' גם הפסיקה המובאת שם].

84. מכאן, שגם הרחבה תחת קרקע הבית המשותף , אף אם היא מיועדת למחסן , מהווה הרחבה במובנו של סעיף 71 לחוק, ובלבד שיהא חיבור פיזי בין ההרחבה לדירה.

94. באשר לאופן מתן ההסכמה הנדרשת במסגרת סעיף 71 לחוק , עמדתי היא , כדעת הסוברים כי אין צורך שתיתן דווקא במסגרת אסיפה כללית , ואף הסכמה שהוענקה באופן פרטני על ידי בעלי הדירות עומדת בדרישות החוק, ובלבד שתהיה מפורשת וברורה. יפים לעניין זה קביעותיו של בית המשפט המחוזי בירושלים בע "א 1415/00, אברהם נ' אזרד (לא פורסם), כדלהלן :

"כבר בשלב זה יאמר , כי בסעיף 71 לחוק כלל לא נזכרת הא סיפה הכללית של בעלי הדירות . עניין זה בולט לרקע הוראות אחרות שבחוק. בסעיף 159 לחוק הוסדר נושא התקנת מעלית . בסעיף זה נקבע שבעלי דירות שבבעלותם שני שלישים מהדירות רשאים להחליט באסיפה כללית על התקנת המעלית (בכפוף לקיום תנאים מסויימים). והנה, בסעיף 71 לא נזכרת אסיפה כללית ודובר אך בהחלטה. מכאן שהמחוקק לא דרש כינוס אסיפה . איננו רואים מדוע החלטה כאמור לא יכולה להתקבל גם בכתב , כאשר בעלי הדירות רשמים את עמדתם בדרך של הסכמה או התנגדות ... בר"ע 6339/97



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

סלומון נ' רוקר, דינים – עליון, כרך נז', 313, בסעיף 33 לפסק דינו של כב' השופט אנגלרד, נאמר, בהערת אגב, כדלהלן: "בסוגית בנייה ברכוש המשותף, המחוקק עצמו ריכך את הדרישה להסכמת כל הדיירים...כמובן, החוק עדיין דורש הסכמה של רוב מיוחד של הדיירים...". מהציטוט הנ"ל עולה כי העיקר הוא ההסכמה וכך יש להבין את המונח "החלטה" שבסעיף 71 לחוק...כחלק ממגמת ההקלה לא נדרשת גם החלטת אסיפה כללית, אלא החלטת בעלי הדירות...". (ההדגשות לא במקור).

[ר' עוד: ת"א (שלום-י-ם) 2998/04 כולל אברכים מצוינים נ' אבנצור חביב אורי, תק-של 2005(3), 1595, 1596 (2005); ת"א (שלום-י-ם) 14565/06 משה שמחוביץ ואח' נ' שפרה גיל ואח' (פורסם באתר נבו); בש"א (שלום-י-ם) 8251/07, שטיין נ' קוצר (פורסם באתר נבו) כן ר' א. איזנשטיין, שם, 217].

05. אין צורך אפוא כי ההסכמה תינתן במסגרת האסיפה הכללית, ואף הסכמה שניתנה על ידי בעל דירה באופן פרטני, הסכמה היא, ובלבד שיהא ברור מתכנה כי בעל הדירה ויתר על זכותו הקניינית והסכים לניצול אחוזי הבניה [ר' למשל ע"א 5043/96 גלמן נ' הררי, פ"ד נ"ד(3), 389].

15. חתימת בעל הדירה על תכנית בניה המוגשת לרשויות התכנון, אכן עשויה להוות ראיה טובה לכך כי הוא הסכים לבניה המבוקשת, על כל המשתמע מכך. יפים לעניין זה דברי בית המשפט העליון בע"א 815/81 יעקב כליפא נ' אלי שאול, פ"ד לו(3), 78, כדלקמן:

"...ברור למדי, שהמפקח דן להלן בהסכמה מפורשת, ואת המצאת העתק התכנית של קווי בנייה הוא מזכיר כראיה להסכמה מפורשת. יש לדייק כאן, שהמפקח התכוון בדבריו אלה בעליל להמצאת תכנית מלכו הנ"ל על-ידי המשיב בעת הפגישה עם יתר בעלי הדירות, ולא להזמנת התכנית החדשה של המודד ביזמת המערערים, שבאה אחרי פגישה זו וכתוצאה ממנה. לגוף הענין, היה יסוד מספיק לממצאו של המפקח, שהמשיבים אכן הסכימו לבנייה, הסכמה שהותנתה בשינוי קווי הבנין לטובת המשיבים...".

25. הנה כי כן, כל אימת שברור מההסכמה שהוצגה לצורך מתן היתר הבניה, כי בעל הדירה ידע מה מהותה של הבקשה והסכים לבניה המבוקשת, יש לראות בכך הסכמה מצדו להרחבת הדירה וניצול אחוזי הבניה במסגרת סעיף 71 לחוק [השווה עוד: ע"א 432/83 מזרחי נ' חביב, פ"ד מ(4), 673, וכן מ. דויטש, קניין [א], 695].



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

35. סוגיה נוספת ב הקשר להסכמה המוצגת , אליה יש להידרש בטרם נפנה לגופו של עניין , נוגעת ל נושא נטלי ההוכחה המוטלים על הצדדים , עת הם ח לוקים בשאלת קבלת ההסכמה. ככלל, מקום בו מבקש בעל דירה לבצע הרחבה על הרכוש המשותף , עליו הנטל להוכיח כי באמתחתו ההסכמה הנדרשת בחוק . העברת הנטל על כתפי הנתבע , בניגוד לכלל, נובעת מייחוד יותר של ההוראה הקבועה בסעיף 71 לחוק , המתירה לרוב מיוחד לפגוע בקניינו של המיעוט [ר' א. אייזנשטיין, שם, 213-211]. זה גם הטעם לכך שעל מבקש ההרחבה להוכיח הסכמה פוזיטיבית לבניה המבוקשת , והוא לא יוכל לטעון להסכמה בהיעדר התנגדות של בעל דירה אחרת [בכך יש לדחות את טענת הנתבעת כי היעדר התנגדות מטעם התובעים לבקשה להיתר בניה, כמוה כהסכמה].

45. יחד עם זאת, מבקש ההרחבה יצא ידי חובתו, בהצגת מסמך המעיד על הסכמה מפורשת כאמור, וככל שהציג מסמך כזה , הנטל להפריך את ההסכמה חוזר לכתפי התובע , ככל תובע שעליו נטל הראיה במשפט האזרחי.

55. על רקע הדברים המובאים , נבחן האם במקרה דנן הוכח שלנתבעת קיים הרוב הדרוש לפעולות המבוקשות על ידה . בתוך כך , אתייחס כמובן לרוב הדרוש בכל מקרה ומקרה , ולסוגיות הנוספות שבמחלוקת בין הצדדים, ככל שיהא צורך בכך.

65. **ההרחבה שמטרתה בניית ממ"ד :**

75. כאמור, תנאי בסיסי לביצוע ההרחבה לשם בניית ממ"ד, הינו הצגת הסכמות של שישים אחוזים מ בעלי הדירות . מאחר ש בבית המשותף דנן 6 דירות, לצורך הרחבה כזו , על הנתבעת להציג הסכמות של מי שבבעלותם "3.6" מהדירות.

85. הנתבעת טוענת כי בידיה הסכמותיהם של בעלי דירות 1 (הנתבעת עצמה), 2 (עובדיה), 3 (צור), ודירה מס' 6, המצויה בבעלות התובעים אך מוכרכת לסמט אשר העניקו הסכמתם לנתבעת. לתובעים טענות רבות כנגד ההסכמות הללו. נבחן אפוא את טענות הצדדים ביחס לכך.

95. **דירות מס' 2-3 – ה"ה עובדיה וגב' צור :**

06. לטענת התובעים, הסכמת בעלי דירות אלו ניתנה על גבי הטפסים המוגשים לצורך היתר בניה ואין בהם ראיה לצורך ההליך הקנייני . כפי שהובא בהרחבה לעיל, ככל שעולה ממסמך ההסכמה, כי בעל הדירה הבין מהי מהות ההרחבה המבוקשת ואישר בחתימתו את הבניה, חזקה כי הסכים לבניה על הרכוש המשותף ולניצול אחוזי הבניה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

16. במקרה דנן, על גבי כתב ההסכמה עליו חתמו בעלי הדירות נכתב, כי: **"הננו מצהירים כי ראינו את תכניות הבניה ואין לנו התנגדות לכך"**. מכאן, שבעלי הדירות אשר חתמו על כתב ההסכמה ידעו על מה חתמו, והסכימו לבניה המבוקשת כמו גם לניצול אחוזי הבניה באופן המבוקש [שטחי שירות מחסן וממ "ד"]. טענות התובעים בדבר שינויים כאלה ואחרים בתכניות הבניה, לא הפריכו את טענת הנתבעת, הנתמכת באמצעות חתימת בעלי הדירות כאמור, כי הם ידעו מהי מהות הבניה המתבקשת והסכימו לכך.
26. כמוסבר לעיל, יש גם לדחות את טענת התובעים, כי היה על הנתבעת לזמן את בעל הדירות החתומים על כתב ההסכמה, להעיד על חתימתם. משעה שהוצג המסמך המעיד על חתימת בעל הדירה, ונוכח העובדה כי הנתבעת הצהירה כי בעלי הדירות חתמו בפניה על ההסכמה [ר' נספח ב' לתצהיר הנתבעת], הנטל להפריך את ההסכמה הועבר לכתפי התובעים. התובעים בחרו שלא לזמן את בעלי הדירה לעדות, ולפיכך יש לראות זאת דווקא כראיה לחובתם [ר': ע"א 548/78, שרון נ' לוי, פ"ד, ל"ה(1), 736, ע"א 2275/96, לימה נ' רוזנברג, פ"ד מז(2), 605, ע"א 27/91, קבלו נ' שמעון עבודות מתכת, פ"ד מט(1), 450]. זה המקום להעיר, כי בכל הנוגע לה"ה עובדיה, על גבי מסמך ההסכמה מופיעים שמותיהם של בני הזוג, אך לכאורה מתנוססת רק חתימה אחת על מסמך ההסכמה. ברי, כי ככלל, על שני בני הזוג, כבעלים במשותף של מחצית הזכויות כל אחד, ליתן הסכמה להרחבה. עם זאת לאור עדות הנתבעת בתצהירה [סעיף 9 לתצהיר הנתבעת] כי בעלי הדירה הידועה כתת חלקה 2, נתנו את הסכמתם הפוזיטיבית לבניה, ובהיעדר טענה כלשהי כנגד כך על ידי התובעים, יש לצאת מנקודת הנחה כי המדובר בחתימה מטעמם של שני בני הזוג עובדיה, בעלי הזכויות במשותף בדירה מס' 2.
36. נטען על ידי התובעים עוד, כי עובדיה וצור, לא היו רשאים לחתום על הסכמה לבניה, מאחר שהעניקו זכות זו לתובעים במסגרת הסכם הפרשה שחתמו עימם, ונוכח ייפוי הכח הבלתי חוזר עליו חתמו כחלק מהסדר הפרשה הנ"ל [ר' נספחים ח' ו-ט' לתצהיר התובעים]. אכן, כפי שהובא בסיכומי הצדדים, כאשר ניתן ייפוי כח בלתי חוזר, מועמדת זכותו של צד ג' אשר לטובתו הוענק ייפוי הכח, במרכז, ואילו אינטרס השולח הופך להיות משני. אולם, יחד עם זאת, מובן כי מהותה של הזכות, הינה אך זו שנוצרה במסמך ההתחייבות שאותה מבקשים להגשים באמצעות ייפוי הכח הבלתי חוזר [ר': א. ברק, חוק השליחות, 1244-1246].
46. בענייננו, מקור ההתחייבות הינם אותם הסכמים שנכרתו בין התובעים לבין עובדיה וצור [נספחים ח' ו-ט' לתצהיר התובעים]. עיון בהסכמים מלמד, כי הם באו להבטיח את הבניה שמבקשים התובעים לבצע בהתאם לאותם הסכמים, קרי, בניה על גג הבית המשותף ובעמודה נוספת בבית המשותף, והכנת תכנית להגדלת אחוזי בניה לצורך כך. ייפוי הכח



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

- הבלתי חוזר נועד אפוא להגשים מטרות אלו, וברר, כי אין בו משום ויתור על כל ל זכויותיהם של צור ועובדיה שאינן קשורות להסכם האמור.
56. הממ"ד המבוקש על ידי הנתבעת, אמור להיבנות מתחת לפני הקרקע, והוא אינו פוגע ב"קונטור" הבית. לא זו אף זו, בניית הממ"ד בשטח של 9 מ"ר, אף אינה מהווה ניצול אחוזי בנייה עיקריים [ר' סעיף 9(ד)1] לתקנות התכנון והבניה (חישוב שטחים ואחוזי בניה בתכניות ובהיתרים), התשנ"ב-1992, וכן תקנה 197א לתקנות ההתגוננות האזרחית (מפרטים לבניית מקלטים), התש"ן-1990. מכאן שההרחבה הנדרשת על ידי התובעת לצורך בניית ממ"ד, אינה קשורה להסכם מים שנכרתו, ולפיכך, אין בהסכמים שנכרתו או ביפויי הכח כדי למנוע מבעלי הדירות ליתן הסכמת לבניית הממ"ד על ידי הנתבעת.
66. פועל יוצא הוא שעובדיה וצור, הם הרשאים ליתן ההסכמה לנתבעת, בכל הנוגע לממ"ד.
76. יתרה מכך, כידוע, סעיף 71ב(ג) לחוק, קובע כי: **"בעל דירה שהורחבה יראה כמי שהסכים להרחבה דומה של כל דירה אחרת באותו בנין"**. והנה, בכל הנוגע לדירה מס' 2 (עובדיה), הרי שכפי שעולה מנספחים ו-ח לתצהיר התובעים, בדירה זו נבנתה תוספת בניה של כ- 21 מ"ר, אשר אמנם בתחילה התקבל פסק דין על הריסתה, אך בסופו של יום הסכימו התובעים על הותרת התוספת על כנה. יש לראות, על כן, בבעלי דירה מס' 2 (הם או מי שבא בנעליהם) כמי שהסכימו להרחבת הנתבעת, וודאי בכל הנוגע לבניית הממ"ד, המשתרע על פני כ- 9 מ"ר בלבד.
86. סיכומו של דבר הוא, כי בכל הנוגע לבניית הממ"ד, הנתבעת עמדה בנטל הנדרש ממנה להוכיח, כי באמתחתה הסכמותיהם של בעלי דירות 2-3.
96. **דירה מס' 6 – דירה בבעלות התובעים ובחכירת ה"ה סמט:**
07. השאלה העקרונית הראשונה הדרושה הכרעה בעניין זה הינה, מיהו הרשאי לחתום על הסכמה להרחבה המבוקשת - התובעים, שהינם בעלי הדירה, או שמא סמט, החוכרים לדורות.
17. שאלה זו אינה פשוטה כלל ועיקר, בין היתר לאור הבדל הנוסח בין סעיפי החוק השונים הדנים בחוכר לדורות של דירה בבית משותף. מחד גיסא, סעיף 52 לחוק קובע כי: **"בעל דירה" – לגבי דירה שהוחכרה לדורות – החוכר לדורות או חוכר המשנה לדורות לפי העניין, זולת אם נקבע בחוזה החכירה שלעניין פרק זה לא יראו אותם כבעלי הדירה** – הוראה זו מעניקה, לכאורה, זכות עדיפה לחוכר לדורות. אולם, במקביל, מאידך גיסא, בסעיף 62 לחוק, אשר סעיף 71ב לחוק מתייחס אליו, נקט המחוקק בניסוח שונה וקבע:



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

"לעניין סעיף קטן (א), "בעל דירה" – לרבות (ההדגשה שלי) המחכיר בדירה המוחכרת בחכירה לדורות ומחכיר המשנה בדירה המוחכרת בחכירת משנה לדורות". לאמור, בהקשר לסעיף 62 לחוק, החוכר מצטרף לעמדת בעל הדירה אך לא בא בנעליו.

27. ואכן, שאלה זו העסיקה את המלומדים השונים. פרופ' וייסמן [י. וייסמן, דיני קניין, בעלות ושיתוף, 442-443], סבור כי שינוי תקנון, וודאי שינוי המגלם הצמדת חלק מהרכוש המשותף לדירה כלשהי, מצריך אמנם את הסכמת החוכר לדורות אך הוא מחייב גם את הסכמת בעל הדירה: **"...כאשר דירה בבית משותף מוחכרת בחכירה לדורות אין די בהסכמה לשינוי תקנון הניתנת על ידי החוכר לדורות של הדירה, על אף ההגדרה של "בעל דירה" שבחוק המקרקעין, תשכ"ט-1969, האומרת כי החוכר לדורות נחשב כבעל הדירה לצורך הפרק על בתים משותפים אם לא נקבע אחרת. נדרשת גם הסכמתו של בעל הדירה לצורך שינוי התקנון"**.

37. דברים דומים מוצאים אנו בדברי פרופ' דויטש [מ. דויטש, קניין, א, 668-669]: **"...יחד עם זאת, בעניין אחד אין חוק המקרקעין מתעלם מן הבעלים הפורמאלי, והוא באשר לקביעת שינוי התקנון בבית המשותף...החלופה אשר שוללת מעמד מן החוכר בסוגיה זו, היא הפרשנות ההולמת יותר לסוגיה. לשינוי תקנון נודעת נפקות של קבע, ובהסכמת הכל אף ניתן לבצע חלוקה שונה של הבעלות ברכוש המשותף, לפגוע בזכויות ועוד..."**. אמנם פרופ' דויטש סבור כי קיים קושי פרשני גם בעמדה זו, ואולם נראה כי סבור הוא שלמרות קושי זה, זוהי העמדה הפרשנית המשרתת את תכליתו של המחוקק. יתרה מכך, לגישתו, אף אם ייקבע שאין בסעיף 62(ג) כדי לשלול את זכותו של החוכר לדורות, הרי שבמקום שהתגלעה מחלוקת בין הבעלים לחוכר, **תהא ההכרעה נתונה לבעלים הפורמאלי** [ר' שם].

47. גישה שונה במקצת מצינו בדברי המלומד אייזנשטיין [א. אייזנשטיין, שם, 137]. המלומד אייזנשטיין, צמצם את זכותו של הבעלים למול החוכר, בכל הנוגע לשינוי התקנון הנוגע לדפוסי ההתנהגות בבית המשותף וקבע כי שינוי כזה דורש דווקא את הסכמת החוכר לדורות. יחד עם זאת, גם הוא סבור כי מקום בו מדובר בנושאים הקשורים לזכות הבעלות, יש משקל לדעת הבעלים: **"חוכרים לדורות...רשאים לערוך תקנון ולשנות את הוראותיו ללא צורך בהסכמת הבעלים...יחד עם זאת יש לציין כי בסעיף 62(ב) לחוק נאמר, שכאשר הדירות מוחכרות בחכירה לדורות רשאים הבעלים (המחכירים) לערוך גם הם תקנון ולשנות הוראותיו. לדעתנו הוראות התקנון שהבעלים רשאים לערוך יכולות להתייחס רק לעניינים הקשורים לזכות הבעלות הכפופה לזכויות החוכרים, כגון, זכויות בניה שלא הוענקו לחוכרים וכד"**.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

57. נמצא, כי הגם שניתן למצוא הבדלים בין גישותיהם השונות של המלומדים, הצד השווה שבהם הוא, כי לצורך וויתור על זכויות קנייניות המוענקות לבעל הדירה עצמו, קרי, חלקו ברכוש המשותף וזכויות הבניה, יש משקל גם לעמדת בעל הדירה, ומקום בו ידוע כי בעל הדירה מתנגד לכך, אין די בהסכמת החוכר לדורות, ודרושה הסכמתו של בעל הדירה הפורמאלי.
67. מן הכלל אל הפרט. במקרה המיוחד דן, אין ספק כי בעל הדירה, התובעים, מתנגדים לבקשת ההרחבה. במקרה זה, לכל הדעות, אין להסתפק בחתימתם של ה"ה סמט, ויש צורך עקרוני לקבל את הסכמת התובעים-הבעלים.
77. יחד עם זאת נראה, כי במקרה דנן, לצורך בניית הממ"ד, כלל לא דרושה הסכמה פוזיטיבית של בעלי דירה מס' 6, שכן מחומר הראיות המונח בפני עולה, כי בדירה מס' 6 קיימת הרחבה דומה, במובנו של סעיף 71ב(ג) לחוק, לזו המבוקשת לצורך בניית ממ"ד.
87. כפי שעולה מנסח הרישום של הבית המשותף [נספח א' לכתב התביעה], שטחה של דירה מס' 6, הינו 45 מ"ר. בפועל, כך על פי עדות התובע, עו"ד שמני, הורחבה דירה מס' 6 במספר מטרים לפני שנים רבות. התובע אף העיד כי: "מדובר בתוספת של כ- 5 מ'. אם אתה אומר שיש תוספת של 8 מ' באופן שמשלמים לפי 53 מ' זה לא מפתיע אותי" [עמוד 2 שורות 27-28 לפרוטוקול]. יש אפוא לצאת מנקודת הנחה כי אכן בוצעה הרחבה של כשמונה מ"ר בדירה מס' 6.
97. ודוק: לא פעם נפסק כי לא בכדי נקט המחוקק בסעיף 71ב(ג) לחוק במונח "הרחבה דומה" ולא במונח "הרחבה זהה". כך הסביר זאת המלומד אייזנשטיין [שם, 234]: "ראוי להדגיש כי סעיף 71ב(ג) הנ"ל מתייחס להרחבה דומה, כלומר, רואים את מי שדירתו הורחבה בגודל מסויים כמי שהסכים להרחבה של כל דירה אחרת שתהיה בגודל דומה להרחבה שאושרה לו. הגודל הדומה אינו חייב להיות בהכרח מדויק ושווה, אלא יכול להיות גודל דומה ושווה בקירוב". כך גם נקבע בעש"א (מחוזי חי) 22123-10-10, חדד נ' זינגר, (פורסם באתר נבו):

"אחד הקריטריונים שנבחן, בנסיבות בהן מבקש בעל דירה לבצע הרחבה דומה בדירתו, מבוסס על השטח הנוסף שבו מבקש בעל הדירה להרחיב דירתו. נדרשת פרופורציה מסוימת, ואם כי לא זהות, בין שטח ההרחבה המבוקש והרחבות קודמות שביצע בעל דירה אחרת בבניין...משנקט המחוקק במונח "הרחבה דומה", ברור הדבר מאליה כי אין לפרש את המונח "הרחבה דומה" על קריטריון בלעדי זה של שטח שנוסף לדירה, שכן אילו לכך התכוון המחוקק, היה קובע במפורש כי יראו את בעל הדירה שהרחיב



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

את דירתו כמסכים להרחבה בשטח ו/או בשיעור דומה, וכאמור, הגדרה זו לא נקבעה בתיקון מס' 18 לחוק המקרקעין. לפיכך, הגם שלא ניתן להתעלם מקריטריון השטח שנוסף, אין זה יכול לשמש כקריטריון בלעדי...." [ר' גם ע"א (מחוזי י"ם) 3235/02, אביב נ' גדולטר (פורסם באתר נבו)].

08. מדברים אלו עולה, כי אין ספק שניתן לראות בתוספת של 8 מ"ר אשר בוצעה בדירה מס' 6, כהרחבה דומה להרחבה של 9 מ"ר לצורך ממ"ד, אותה מבקשת הנתבעת לבצע. פועל יוצא מכך הוא שיש לראות את בעלי דירה מס' 6, מכח סעיף 71ב(ג) לחוק, כמי שמסכימים להרחבה של הנתבעת הנדונה בפרק זה, קרי, הממ"ד.
18. התובעים טענו בסיכומיהם, כי הנתבעת כבר ביצעה "הרחבה דומה", בכך שבנתה מחסן בחצר, ולפיכך אין היא זכאית להרחבה נוספת. אין בידי לקבל הטענה. בעדותה לפני הבהירה הנתבעת כי: **"המחסן בחצר אינו שלי, אין דייר שמשמש בו אני גם לא הקמתי את המחסן. אני משתמשת בו, הוא רעוע מפח" [שורות 10-9 עמוד 10 לפרוטוקול].** בהמשך הוסיפה הנתבעת כי: **"המחסן (נספח ו') הוא לא שלי כפי שאמרתי, אני משתמשת בו, מי שרוצה יכול להשתמש בו" [שורה 25 עמוד 11 לפרוטוקול].** הצהרת הנתבעת, אשר לא נסתרה, שלפיה המחסן אינו שלה וכי לא היא שבנתה אותו, כמו גם עדותה כי כל מי שמעו ניין רשאי לעשות בו שימוש, מחייבת את המסקנה כי לא ניתן לראות בתובעת כמי שביצעה הרחבה באמצעות הקמת המחסן.
28. הנה כי כן, בכל הנוגע לממ"ד, יש לראות בנתבעת כמי שקבלה הסכמותיהם של דירות 1,2,3,6, המהווים 66% מהדירות בבית המשותף, ומכאן שהנתבעת הוכיחה כי בידה הרוב הדרוש לבניית הממ"ד, בהתאם לסעיף 71ב לחוק.
38. בטרם סיום נושא זה, ולמעלה מהדרוש יוסף, כי גם את טענת התובעים בעניין ההכרח לבנות את חדרי הממ"ד דווקא בעמודה המוצעת על ידם יש לדחות. ראשית, כלל לא ברור שניתן להקים במיקום זה ממ"ד תקני. בנוסף, היתר הבניה שהוצא על ידי הרשות התכנונית המופקדת על כך מעיד כי הבניה תואמת את דיני התכנון והבניה ואת תקנות ההתגוננות הרלוונטיות. בעניין זה אף יוער כי לא נסתרה טענת הנתבעת, כי השטח המצוי בקרקע הבית המשותף משתרע על פני 147 מ"ר, וממילא, בנסיבות העניין, ונוכח ההסכמות שהוענקו, אין מקום לחייב את הנתבעת לבנות את הממ"ד במיקום שהינו, לטענתה, פחות נח לה.
48. סיכומו של דבר, שיש לראות בנתבעת כמי שיש בידה את הרוב הדרוש להרחבה שמטרתה בניית ממ"ד בחלל שתחת דירתה.



משרד המשפטים
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

58. **ההרחבה שאינה לצורך בניית ממ"ד:**
68. כמובא לעיל, לצורך הרחבה שאינה לשם בניית ממ"ד, דרושה הסכמת שלושה רבעים מבעלי הדירות אשר שני שלישים של הרכוש המשותף צמוד לדירותיהם. במקרה דנן, דרושה, אפוא, הסכמה פוזיטיבית של בעליהן של 4.5 מתוך שש הדירות שבבית המשותף.
78. אין חולק, כי בעליה של דירה מס' 4 לא נתנה הסכמתם לנתבעת. אין גם חולק כי התובעים, בעלי דירה 5 לא נתנו הסכמתם. אין גם מחלוקת כי בדירה מס' 5 לא בוצעה הרחבה שיש לראות בה הרחבה דומה למבוקש על ידי הנתבעת. בכל זאת, טוענת הנתבעת כי ברשותה הסכמת 5 דירות בבית המשותף. לטענת הנתבעת, יש לראות בתובעים, בעלי דירה 5, כמי שנתנו הסכמתם, מכח הרחבה דומה אשר ביצעו התובעים, לטענתה, בדירה מס' 6 שאף היא בבעלותם.
88. אינני מקבל הטענה. הבחינה האם קיימת הרחבה דומה, הינה בחינה פרטנית לכל דירה ודירה, ורק דירה שבוצעה בה הרחבה דומה, יתישב כדירה אשר בעליה הסכימו להרחבה המתבקשת על ידי בעל דירה אחרת. במילים אחרות, עת נבחנת השאלה האם בוצעה הרחבה דומה לצורך סעיף 72(ג) לחוק, זהות הבעלים אינה רלוונטית כלל וכלל, וכל דירה נבחנת בגפה.
98. אין אפוא לראות את בעלי דירה מס' 5 כמי שהסכימו להרחבה.
99. לאור מסקנתי זו, הרי שאף אם תתקבלנה כל טענות הנתבעת לעניין הסכמת בעלי הדירות 2,3,6 [ואינני מכריע בכך, שכן הכרעתי לעיל התייחסה לבניית ממ"ד בגודל של 9 מ"ר, על כל המשתמע מכך] לנתבעת הסכמת בעלי 4 דירות בלבד, וממילא אין בידה את הרוב הדרוש [75% מבעלי הדירות] להרחבה שלא לשם ממ"ד.
19. דין התביעה בכל הנוגע להרחבה שאינה ממ"ד להתקבל אפוא.

ה. סיכומו של דבר:

29. לאור כל המוסבר לעיל, ונוכח ההסכמות שקבלה הנתבעת, רשאית היא להרחיב את דירתה אך ורק לצורך בניית ממ"ד, אך היא אינה רשאית להרחיב דירתה למטרה אחרת.
39. מאחר שעל פי היתר הבניה שהוצג בפני, המעבר לממ"ד עובר בשטח שלא ניתן להצמדה לדירת הנתבעת, הרי שכל שהנתבעת מעוניינת לבנות את הממ"ד, עליה לבצע את ההתאמות והשינויים הנדרשים לצורך כך. למען הסדר הטוב יוער, כי ככל שיתברר, כי



משרד המכס
לשכת המפקח על רישום המקרקעין
ירושלים

בניית הממ"ד מחייבת הצמדת שטח מסוים נוסף ברכוש המשותף לשם מעבר לממ"ד, יהיו רשאים הצדדים להעלות טיעוניהם בפניי לעניין זה, ולעניין זה בלבד.

49. בסיכומיהם דרשו התובעים, כי יינתן צו המורה לנתבעת להשיב המצב לקדמותו, ולא להסתפק בצו המורה לנתבעת לאטום את החפירה שבצעה. מובן, כי לאור מסקנתי לעיל, אין כל מקום לדרישה זו בנוגע לממ"ד. יתרה מכך, על רקע התנהלות הצדדים בפרשה, לא מצאתי מקום לדרישה זו גם ביחס ליתרת השטח החפור, וסבורני כי במקרה דנן די במתן צו המורה על אטימה מוחלטת של השטח, באמצעות יציקת בטון, ומתן צו האוסר על שימוש כלשהו בשטח שנחפר (למעט הממ"ד כאמור). צווים אלו, ימנעו מהנתבעת שימוש בשטח זה מחד גיסא, ולא יפגעו פגיעה מיותרת בנתבעת מאידך גיסא. סייג לכך, הינו מקום בו רשות תכנונית תקבע כי היעדר המילוי גורם לניצול זכויות בניה, שבמקרה כזה, לאור הפגיעה הנגרמת, יש מקום לחייב את הנתבעת להשיב המצב לקדמותו.

59. אשר על כן, אני מורה לנתבעת לבצע את ההתאמות הנדרשות בהתאם לפסק דין זה, לאטום באופן מוחלט, באמצעות יציקת בטון, את כל השטח שאינו משמש לממ"ד, ונותן צו האוסר עליה להשתמש בשטח האמור. ככל שתקבע רשות תכנונית מוסמכת, בהחלטה חלוטה, כי זכויות מאן דהוא בביית המשותף נפגעות בשל היעדר מילוי, יהא על הנתבעת להשיב המצב לקדמותו, למעט בכל הנוגע לממ"ד כאמור לעיל.

69. כל עוד לא יושב המצב לקדמותו, ועל מנת שלא ייטעה צד ג' בדבר האפשרות לבצע שימוש בחפירה, אני מורה גם על רישום הערה לפי סעיף 130 לחוק בדירת הנתבעת [נתת חלקה 1 בגוש 30010 חלקה 49] בדבר קיומו של פסק הדין.

79. לאור העובדה שלפיה התביעה התקבלה בחלקה ונדחתה בחלקה, יישא כל צד בהוצאותיו.

ניתן היום, י"ג אב תשע"ב, 01 אוגוסט 2012, בהעדר הצדדים, וישלח לידם בדואר רשום.

ש. הייזלר

מפקח בכיר על רישום המקרקעין